



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 218/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

התובעים: 1. עזרא טווינה  
הנתבעים שכנגד: 2. חיה טווינה  
ע"י ב"כ עוה"ד עוז כהן  
מרחוב בית הדפוס 12 ירושלים

הנתבע: רפאל מכלוף  
התובע שכנגד: ע"י ב"כ עוה"ד גיל טואף  
מרחוב בלוח 11 תל אביב

### פסק דין

התובענה דנן עניינה בבית המשותף ברחוב סמדר 8 רמת גן הבנוי על חלקות 181-182 בגוש 6203 (להלן: "הבית").

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.

התובעים הינם בעלי דירה בקומה ראשונה בבית הידועה כתת חלקה 2 (להלן: "דירת התובעים") ולה צמוד גג בשטח של 126.52 מ"ר. הנתבע הינו הבעלים של דירה בקומת הקרקע בבית, הממוקמת מתחת לדירת התובעים, והידועה כתת חלקה 1 (להלן: "דירת הנתבע").

כתב התביעה עוסק בשלוש עילות מרכזיות:

1. התובעים טוענים כי הם ביצעו עבודות בנייה בדירת התובעים לרבות הוספת קומה על גג הבית. הנתבע פנה בתביעה בתיק 319/08 בפני המפקחת הבכירה מירה אריאלי (להלן: "ההליך הקודם") במטרה למנוע את הליך הבניה אולם תביעתו נדחתה. דא עקא, בפסק הדין נאסר על התובעים "להתקין צנרת מים ו/או ביוב על הקירות החיצוניים של הבית". לאחר ההליך הנ"ל ניהל הנתבע הליך נוסף כנגד התובעים בית משפט השלום בתיק 20614-03-10 (להלן: "ההליך בשלום"), במסגרתו הוסכם על מינויו של מומחה מטעם בית המשפט ומתן פסק דין על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט. בהליך בשלום מונה המומחה חיט אשר קבע כי לא ניתן להשתמש בצנרת הפנימית הרקובה ויש צורך בהתקנת צנרת חיצונית חדשה. על אף חוות הדעת האמורה ומו"מ שנוהל בין הצדדים עומד הנתבע בסירובו ומתנגד להתקנת צנרת חיצונית חדשה. לטענת התובעים נוצרו נסיבות חדשות מאז מתן פסק הדין בהליך הקודם, במיוחד כאשר המדובר בצו מניעה לגביו נתונה תמיד הרשות לחזור לבית המשפט ולבקש את ביטולו או שינויו, ואלו מצדיקות מתן פסק דין הצהרתי לפיו רשאים התובעים להתקין צנרת ביוב חיצונית. לטענת התובעים מאז מתן פסק הדין בהליך הקודם השתנתה התפיסה בנוגע ל"שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף" ויש גם בכך להצדיק מתן הצו ההצהרתי כמבוקש. לחילופין טוענים התובעים כי יש לחייב את הנתבע בתשלום ההפרש שבין חיבור הצנרת הפנימית לבין התקנת צנרת חיצונית.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 218/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

2. התובעים טוענים כי הנתבע מסרב להשתתף בהוצאות לתחזוקת הבית ולפיכך נתבקש צו עשה אשר יחייב את הנתבע לשאת בכל התשלומים הנדרשים להחזקת הרכוש המשותף ובכלל האמור בהוצאות הדרושות לתיקון בעיית הרטיבות במקלט ובקירות הבית.
3. התובעים טוענים כי הנתבע התקין פרגולה בגינה המשותפת, ללא קבלת הסכמתם ושלא כדין, ולפיכך יש להורות על הריסתה.

הנתבע הגיש כתב הגנה וטען כי אין המדובר אלא בניסיון שלישי של התובעים לקבל אישור בערכאות משפטיות להתקנת צנרת ביוב חיצונית בבית. ניסיון זה נדחה בפסק הדין בהליך הקודם במסגרתו, לאור עדותו של מומחה כי ניתן להתקין מחדש את צנרת הביוב שהוסרה על ידי התובעים (התובעים דנו) עובר לדיון, ניתן צו האוסר עליהם להתקין צנרת ביוב כאמור. גם בהליך בבית משפט השלום חויבו התובעים לתקן על חשבונם את צינור הביוב הקיים תוך שנקבע כי השופט הדן בתובענה נמנע במכוון מלתן צווים לעניין הליכים המתנהלים בפני מותב אחר, בהליך הקודם. לטענת הנתבע לא חל כל שינוי בנסיבות, ובודאי שלא כזה המצדיק שינוי של פסק דין סופי לגבי קם מעשה בי-דין. מכל מקום, גם לגופם של דברים טוען הנתבע אין מקום להתיר התקנת צנרת חיצונית ללא קבלת הסכמת בעלי הדירות. בהקשר זה, דווקא התנהלות התובעים נגועה בחוסר תום לב. הנתבע טוען כי מאז רכשו התובעים את דירתם הם מצויים בהליך מתמיד של בניה ושיפוצים מבלי שהם דואגים לרכוש המשותף בבית. דווקא הנתבע מימן מכיסו הוצאות להחזקת הרכוש המשותף בבית. הנתבע מכחיש כי התקין פרגולה בחצר, לטענתו המדובר בסוכה מתפרקת לחג סוכות.

ביחד עם כתב ההגנה הגיש הנתבע תביעה שכנגד במסגרתה טען כלהלן:

1. הנתבעים שכנגד אטמו שלא כדין את פתח הכניסה לחלקים המשותפים בגג הבית ויש להורות על פתיחתו מחדש ומתן מפתח לתובע שכנגד.
2. הנתבעים שכנגד סגרו חלק מהמרפסת בחזית הבית והתקינו חלון קטן שלא כדין. הדבר פוגע בחזות הבית ומכער אותו ויש להורות על החזרת מצב הרכוש לקדמותו.
3. הנתבעים שכנגד גרמו למוקדים של רטיבות ולכלוך בכל קירות הבית בשל עבודות אינסטלציה שביצעו בדירתם ועליהם לתקן את הנזקים שגרמו ולצבוע את קירות הבית בצבע לבן.
4. הנתבעים שכנגד מאחסנים בשטח הרכוש המשותף ציוד בניה רב ופסולת ועליהם לסלקם.
5. על הנתבעים שכנגד להשיב לתובע שכנגד הוצאות שהוצאו על ידו לניקיון הבית בשל עבודות הבניה והשיפוץ שביצעו הנתבעים שכנגד בסך של 14,000 ₪.

הנתבעים שכנגד טוענים כי יש לסלק את התביעה שכנגד על הסף מחמת מעשה בי-דין, שכן, הסעד הקשור במתן גישה לגג נדון כבר ונדחה בהליך הקודם. כך גם את כל הסעדים האחרים הנתבעים בהליך דנו צריך היה התובע שכנגד לכלול בהליך הקודם או בהליך בשלום בהתאם להוראות תקנה 44 לתקנות סדר הדין האזרחי. לגופם של דברים טוענים הנתבעים שכנגד כי הגג מעל דירתם צמוד לדירתם ולא היה כל פתח לגג כנטען על ידי התובע שכנגד. מכל מקום הבניה על הגג בוצעה על פי



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 218/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

היתר חלוט ללא כל אפשרות גישה לגג לתובע שכנגד. הנתבעים שכנגד לא רק שלא פגעו בחזות הבית אלא שהם אף שיפרו אותה, כפי שעולה גם מפסק הדין בהליך הקודם. החלון שהותקן על ידם הותקן גם על ידי בעלי דירות אחרים בבית ואין הוא פוגע במראה הבית. בכל הקשור לטענות בדבר רטיבות הרי שטענות אלו נדונו כבר והוכרעו במסגרת ההליך בשלום. הנתבעים שכנגד עושים שימוש סביר ברכוש המשותף לצורך הנחת חומרי בניה, באופן זמני, עד לגמר הבניה, שמתעכבת רק בעטיו של התובע שכנגד. מכל מקום אין לנתבעים שכנגד כל רצון או אינטרס להותיר את הצידוד במקום. התובע שכנגד אינו זכאי להשבת הכספים הנטענת בהתאם להוראות הדין וההלכה הפסוקה ומכל מקום הסכומים הנתבעים מופרכים.

ביום 24.07.11 נערך דיון מקדמי בתובענה ובסיומו נקבעה פרוצדורה לשמיעת ראיות.

מטעם התובעים/נתבעים שכנגד הוגש תצהירו של מר עזרא טווינה וכן חוות דעת המהנדס מרדכי בס. בנוסף ביקשו התובעים לזמן לעדות את המהנדס יצחק חוט.

מטעם הנתבע/התובע שכנגד הוגש תצהיר הגב' פנינה מור ברדה מכלוף וחוות דעת המהנדס חיים קליין.

ביום 07.12.11 נערכה ישיבת הוכחות במסגרת נחקרו העדים ולאחריה סיכמו הצדדים בכתב את טענותיהם.

## דיון

### התביעה העיקרית

#### *התקנת צנרת ביוב*

אין מחלוקת כי בפסק הדין בהליך הקודם נאסר על התובעים להתקין צנרת מים ו/או ביוב על הקירות החיצוניים של הבית. המחלוקת בהליך דנן הינה האם המדובר במעשה בי-דין והאם התגלו נסיבות חדשות המצדיקות עיון מחדש בצו שניתן.

בע"א 127/06 בנק הפועלים בע"מ – משכן נ' לאה נגר (פורסם בנבו) מסכמת כבוד השופטת חיות את ההלכות בנוגע לכלל בדבר מעשה בית דין:

"הכלל בדבר מעשה בית דין משמעו כי צדדים להליך מנועים מלחזור ולהתדיין ביניהם בבית המשפט בכל עניין או שאלה שנדונו והוכרעו בפסק דין סופי. בבסיס הכלל עומדים טעמים שבטובת הציבור שעיקרם הפעלה יעילה של מערכת בתי המשפט ומניעת כפל התדיינות והכרעות סותרות העלולות לפגוע ביציבות המשפט ובוודאות ההחלטות הניתנות מכוחו. כמו כן מיועד הכלל של מעשה בית-דין להגן על האינטרסים של בעלי הדין ולמנוע ממי שניתנה לו הזדמנות הוגנת ומלאה



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 218/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

**למצות את עניינו בבית המשפט לשוב ולהטריד את יריבו באותו עניין** (ראו: משה קשת הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי - הלכה ומעשה 666 (כרך א', 2007) (להלן: קשת); ע"א 3097/02 מלמד נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י, פ"ד נח(5) 511, 519 (2004); ע"א 4087/04 גורה נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פסקה 7 (לא פורסם, [פורסם בנבו], 8.9.2005) (להלן: עניין גורה); מיכאל בן-יאיר "הרחבת תחולתו של מעשה בית דין על מי שלא היה צד להליך קודם" ספר יצחק כהן 302 (1989)).  
הדוקטרינה של מעשה בית דין נחלקת לשני ראשים.

הראש האחד עניינו בהשתק עילה ולפיו פסק דין סופי שניתן לגופו של עניין מעניק לנתבע (או לחליפו) חסינות מפני תביעה נוספת של התובע (או חליפו) בגין אותה עילת תביעה. בהקשר זה ניתנה למושג "עילת תביעה" משמעות רחבה במטרה להגשים את תכלית הכלל ולמנוע את הטרדת הנתבע בתביעות חוזרות בשל אותו מעשה (ראו: ע"א 303/79 אבני נ' גליקסמן, פ"ד לה(1) 98, 92 (1980); ע"א 8/83 גורדון נ' כפר מונאש - מושב עובדים, פ"ד לח(4) 797, 801 (1985); רע"א 6498/05 צבעוני נ' בנק הפועלים בע"מ - סניף עפולה עלית (לא פורסם, [פורסם בנבו], 23.2.2006)).

הראש השני הוא השתק פלוגתה, ולפיו כאשר פלוגתה, על רכיביה העובדתיים והמשפטיים, הוכרעה באופן פוזיטיבי בפסק דין סופי (במפורש או מכללא), ההכרעה היתה חיונית לתוצאה הסופית ולבעלי הדין "היה יומם" ביחס לאותה פלוגתה, יהיו בעלי הדין (או חליפהם) משותקים מלהתדיין לגביה שוב (ראו: נינה זלצמן מעשה בית-דין בהליך אזרחי, 3-4, 29, 137-141 (1991) (להלן: זלצמן); ע"א 246/66 קלוזנר נ' שמעוני, פ"ד כב(2) 561, 583-585; עניין גורה, פסקה 7).  
יודגש כי כאשר הפלוגתה היא בשאלה מעורבת של חוק ועובדה כלל ההשתק חל הן על הממצאים העובדתיים והן על המסקנה המשפטית הנגזרת מהם (ראו זלצמן, 164. אך ראו הסייגים לכלל במשפט הפילי וּבמשפט האזרחי: ע"פ 447/88 לוונטהל נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(2) 1, 6 (1990); ע"א 1418/90 מאור נ' הרשנהורן, פ"ד מה(3) 95, 102-105 (1991); ע"א 1351/06 עו"ד ח'ורי נ' חברת ארמון ההגמון (קסר אלמוטראן) בע"מ, פסקאות ל"א(2)-ל"ו (לא פורסם, [פורסם בנבו], 17.9.2007); ע"א 5610/93 זלסקי נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ראשון לציון, פ"ד נא(1) 68, 98-100 (1997). ולחסרונותיו של הכלל ראו רע"א 682/07 לבייב נ' גילר, פסקה יא' (לא פורסם, [פורסם בנבו], 20.6.2007); אליהו הרנון "הפלוגתה הפסוקה (Collateral Estoppel) כמעשה בית-דין" הפרקליט כג 344, 352-353 (1967) ((ההדגשה שלי, א.ס.)).

לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים בהקשר זה אני קובע כי חל במקרה דנן מעשה ביי-דין מסוג השתק פלוגתה.

ראשית, כל הרציונלים העומדים בבסיס הכלל בדבר מעשה ביי-דין מתקיימים - המדובר בהתדיינות חוזרת בנושא שהוכרע באופן סופי וברור והליך זה הינו אך כפל התדיינות אשר עשוי להביא להכרעות סותרות. מפסק הדין בהליך הקודם עולה כי רובו ככולו עוסק בסוגיית הנחת הצינורות על



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 218/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

הקירות החיצוניים (עמוד 2 לפסק הדין). גם נפגע כאן אינטרס הנתבע לפיו, לאחר שכבר ניתנה לתובעים הזדמנות הוגנת ומלאה למצות את עניינם בבית המשפט, לא ינוהל שוב דיון באותו עניין.

שנית, גם המבכנים בדבר קביעת קיומו של הכלל בדבר השתק פלוגתה חלים - מפסק הדין בהליך הקודם עולה כי הקביעה בו לא באה אלא לאחר שניתן לצדדים יומם בבית המשפט.

מפסק הדין גם ברור כי כוונת המפקחת הבכירה אריאלי היתה לאסור על התובעים דנן באופן גורף להתקין צנרת ביוב חיצונית על קירות הבית. ובמה דברים אמורים. בפסק הדין קביעה עובדתית כי "הצנרת שהנתבעים הניחו על הקירות החיצוניים רובה ככולה הוסרה". בכך, לכאורה, אמור היה להסתיים פסק הדין לאור הסעד לו עתר התובע שם (ר' עמוד 1 לפסק הדין). דא עקא, על אף האמור לעיל, ולאור עדותו של המהנדס אדלר, מצאה המפקחת לנכון ליתן צו "האוסר על הנתבעים להתקין צנרת מים ו/או ביוב על הקירות החיצוניים של הבית". כלומר, אין ולא יכולה להיות מחלוקת כי קביעתה של המפקחת אסרה על כל התקנה של צנרת ביוב חיצונית בבית, גם כל צנרת עתידית, בבחינת "סוף פסוק" עובדתי ומשפטי.

לאור העובדה כי המדובר באותו הבית, באותם הצדדים ובאותה שאלה משפטית ועובדתית העומדת על הפרק, אזי שקם הכלל בדבר מעשה בי-דין ואין לאפשר התדיינות מחדש לגבי אותה הכרעה.

למעשה, בנסיבות המקרה דנן, קם גם מעשה בי-דין מסוג השתק עילה - העילה המהותית שנדונה בהליך הקודם, האם התקנת צנרת הביוב על קירותיו החיצוניים של הבית מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף, הינה אותה העילה הנדונה גם בהליך דנן.

אולם בכך לא די לצורך בחינת התובענה שבפנינו. התובעים טוענים כי יש מקום לעיון מחדש באותו פסק דין לאור קיומן של נסיבות חדשות. טענת התובעים היא כי לאור ההליך בשלום ומחוות דעתו של המומחה חייט שמונה במסגרת אותו ההליך, עולה כי לא ניתן להתחבר לצנרת הביוב המקורית בבית.

אין סתירה בין הקביעה כי חל מעשה בין דין כאמור לעיל לבין טענת התובעים לקיומה של אפשרות לעיון מחדש בצו מניעה קבוע שניתן. ההכרעה בהליך הקודם מחייבת כל עוד מערכת הנסיבות הקשורה בה נותרה זהה. בנסיבות שכאלו קם, למעשה, מעשה בי-דין (ובמקרה דנן השתק פלוגתה והשתק עילה כאמור). אולם, שינוי דרסטי בנסיבות ששימשו בסיס ויסוד לאותה הכרעה בהליך הקודם, מקים, למעשה, מעין עילה חדשה. ככל שהעובדות המהותיות משתנות באופן משמעותי, אין דיני מעשה בי-דין מונעים דיון באותן עובדות חדשות, שלמעשה לא עמדו להכרעה במסגרת ההליך הקודם (ר' בהשלכה לענייננו ע"א 116/82 עמיקם לבנת נ' יצחק טולידאנו פ"ד לט (2) 729). כך, למשל, בתובענה למתן צו האוסר על נתבע לבצע עבודות בניה ברכוש המשותף בהעדר קבלת הסכמה כדין של בעלי הדירות. אף אם יינתן צו מניעה קבוע האוסר על הנתבע לבצע את הבניה, היעילה על הדעת כי הנתבע לא יוכל לעתור לביטול צו המניעה (אף אם הבניה המבוקשת על ידו זהה לזו שנדחתה קודם לכן) אם וככל שיתקבלו בידו בהמשך ההסכמות הנדרשות על פי דין ? !



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 218/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

בהקשר זה אעיר כי אין באשר נפסק בה"פ 1630/04 (אוזכר על ידי הנתבע בסיכומיו) כדי לשלול את האמור לעיל. בפסק הדין שם נטען כי צו מניעה/עשה קבוע אינו מקים מעשה בי-דין וטענה זו נדחתה. לא נדון שם כלל נושא של שינוי נסיבות, כפי שהעלו התובעים בהליך דנן.

לאחר שקילת הראיות הרי שבמקרה דנן לא התרחשו אותן נסיבות חריגות מתאימות המאפשרות עיון מחדש בסעד הקבוע שניתן. למעשה, המערכת העובדתית לפיה נקבעו ההכרעות בהליכים הקודמים נותרה, במהותה, זהה.

מעדויות כל המומחים שבפני עולה באופן ברור כי מבחינה הנדסית הדרך הטובה ביותר להתקנת הביוב הינה באמצעות צנרת ביוב חיצונית חדשה מדירת התובעים. יתרונות התקנת צנרת ביוב כנ"ל ביחס לתיקון מערכת הביוב הקיימת הן בעלותה הנמוכה, ביכולת להגדיל את נפח הסליקה ובגישה. כל המומחים מסכימים כי גם ניתן להתקין מערכת ביוב חדשה שאינה דולפת ואין בה ליצור מפגעים כלשהם. דא עקא, **כל המומחים גם מסכימים כי צנרת הביוב הקיימת תקינה וכי ניתן לבצע עבודות כדי לחבר את דירת התובעים לצנרת ביוב זו**. אומנם אין זו הדרך העדיפה מהבחינה ההנדסית אולם גם דרך זו אפשרית ושימיה.

כך מעיד מר חייט כי "הצנרת הקיימת היא אולי תקינה, כנראה היא תקינה" (עמוד 2 שורה 6). אומנם, בעדותו מעלה מר חייט טענה כי עבודה לחיבור הצנרת הקיימת עשויה להיות מסוכנת לתקרה. אולם, כל הסוגיה ההנדסית הנ"ל לא הוזכרה כלל בחוות דעתו של חייט בהליך בשלום ונושא זה עלה לראשונה רק במסגרת עדותו בפני. הדבר תמוה לאור העובדה כי מינוי המהנדס חייט בהליך בשלום היה בכדי להביא לחיבורה של דירת התובעים למערכת הביוב הקיימת (עמוד 3 שורות 4-7). למעלה מכך, בתשובה לשאלתי משיב מר חייט כי "כדי לעשות את העבודה צריך לעשות חיזוק מלמטה ולעבות את העמוד" (עמוד 2 שורה 17). מר חייט גם מאשר כי הצנרת הקיימת מתאימה מבחינת היקפי הסליקה הנדרשים - "לפי התקן הקיים היום, הצינור הישן יכול להיות מתאים, תלוי בעומס המים שהוא צריך לספוג" (עמוד 2 שורה 27). כלומר, לדעתו של מר חייט, על אף שהמדובר אולי בעבודה שאיננה הנכונה ביותר מבחינה הנדסית, הרי שמכל ההיבטים ניתן לבצע חיבור של מערכת הביוב לצנרת הישנה - "אני כתבתי תיקון לצינור? אמרתי שאפשר לתקן את הצינור כרוך בקונסטרוקציה. ש.ת. אנחנו מדברים על צינור שצריך לתפקד ולכן המהותי זה היחידות" (עמוד 4 שורות 23-24).

כך, למעשה, מאשר בעדותו גם מר בס - "אני לא הלכתי בכיוון של השאלה הזאת. חשבתי שמן הדין ומן הצדק מבחינה הנדסית זה להוציא צינור החוצה כדי להיפרד מחוסר השכנות הטובה שקיימת במקום. זה לא דבר חריג. ברור שאם בכוח יאנסו אותם אז יחברו את הצינור הישן אבל אז צריך להיכנס לשכן לחצוב לעשות לו לנזקים" (עמוד 5 שורות 24-26) (ההדגשה שלי, א.ס.).

כך גם מאשר מר קליין כי מבחינה הנדסית עדיפה התקנת צנרת פלסטיק חיצונית חדשה. אולם, גם החלופה של התחברות למערכת הישנה קיימת ואפשרית - **"שתי החלופות אותו דבר. מקובלות עליו**. אם הייתי גר שם למטה למשל אני הייתי אומר לזרוק את הישן ולבנות חדש מפלסטיק אבל זה



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 218/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

לא מקובל עליה. אם משנים צנרת בפנים צריך לשאול אותה. וזה ישפיע עליהם באופן רציני. זה יעבור ליד החלון וכול טיפול למעלה משפיע על למטה. **ברגע שיש צינור מרכזי מברזל זה גם מקובל עליי.** אני תוקף את זה שהמומחה שני אמר שהצינור חלוד ולא עובד" (עמוד 10 שורות 14-17) (ההדגשה שלי, א.ס.).

בנסיבות אלו, כפי שהן באות לידי ביטוי בעדויות המומחים, הרי שלא ניתן לומר שיש שינוי נסיבות כה קיצוני אשר מצדיק סטייה מהכרעות קודמות בנושא דנן. אומנם, ישנה חלופה הנדסית אפשרית ואולי אף עדיפה של התקנת צנרת פלסטיק חיצונית חדשה. אומנם, העבודות הנדרשות לחיבור צנרת הביוב למערכת הקיימת הינן משמעותיות יותר. אולם, ניתן כבר פסק דין בהליך הקודם בעניין זה ומשלא נשללה לחלוטין האפשרות ההנדסית לביצוע חיבור למערכת הקיימת, לא ניתן לראות בעמדות המומחים כפי שהוצגו ככאלו המשנות באופן מהותי את מערך הנסיבות העובדתיות שהובילו להכרעה בהליך הקודם ובהליך השלום.

וידוגש, גם כבוד השופט שוורץ אשר ישב בדין בהליך בשלום סבור היה כי אין כל מקום להתערב בקביעותיה של ערכאה שיפוטית אחרת, על אף שחוות דעתו של המומחה חיט, אשר מונה כמומחה וכמפקח מטעמו, היא כי חיבור חיצוני עדיף. בהליך בשלום נקבע כי על המומחה חיט לפקח על העבודות המבוצעות לחיבור הדירה למערכת הביוב הישנה – "הפרוטוקול מהד' למרץ. לא מוזכר עניין היציבות שאמרתי מקודם. נאמר לי שכב' השופט שוורץ הורה לעשות חיבור לצינור הקיים. הקבוצות זה הדבר העיקרי. יש בעיה של אי יציבות. אני רוצה לקיים את ההוראות של בית המשפט אבל אי אפשר כי צריך לעשות חיזוקים שאין בהם טעם. זה היה גוזל מהם שטח של דירה דווקא מהדירה למטה של הנתבעים" (עמוד 3 שורות 4-7).

נוסף לכך הרי שתיקון צנרת הביוב הקיימת, לבד מחיבור דירת התובעים אליה, יאפשר גם לחבר מחדש את חדר השירותים של דירת הנתבע אשר נותק לאור חיתוך צינור הביוב וסתימה, למעשה, של צינור האוורור למערכת הביוב בדירת הנתבע (עמוד 10 שורות 5-7).

זאת ועוד. מעדותו של מר חיט עולה כי המקור לבעיות בצנרת הביוב המקורית והצורך בביצוען של עבודות לחיבור דירת התובעים למערכת הביוב נובע בשל עבודות שביצעו התובעים – "ראש הקולטן נשבר מאיזושהי סיבה. קשה לי מאוד להעריך מה הסיבה. קולטנים כאלה שהם מתחת לריצוף לא נשברים מאליהם. ייתכן שזה משיפון או כשרצו לשים שם ריצוף חדש. זה דברים שקורים" (עמוד 3 שורות 15-19). נתון עובדתי זה מהווה משקל משמעותי בהכרעה שלא לסטות מהקביעות בהליך הקודם ובהליך בשלום. שינוי ההכרעות שנקבעו יהווה מעין "מתן פרס" למי אשר גרם במעשיו (בין אם בכוונה, בין ברשלנות ובין בשגגה) לשינוי הנסיבות, ואין להתיר זאת.

לאור האמור הרי שגם אין הצדק לקבלת הסעד החלופי הנתבע בהליך דנן. על התובעים, אשר יצרו את בעיית הביוב בעצם ביצוע השיפון בדירתם, לבצע על חשבונם את כל העבודות הנדרשות לחיבור מערכת הביוב הקיימת.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 218/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

ויוער, לא רק שפעולות התובעים הן אלו אשר גרמו לצורך בביצוע עבודות לחיבור מערכת הביוב הישנה, אלא שהנתבע אף סבל מפעולותיהם החד צדדיות במערכת הביוב המשותפת. התובעים אילצו את הנתבע למצוא פתרונות ביוב אחרים לאור חיתוך צינור האוורור והותרת מערכת הביוב בדירת הנתבע עם ריחות וסתימות בהעדר מערכת אוורור הנדרשת לאיזונים (סעיף ד' בעמוד 12 לחוות דעת קליין וכן עמוד 10 שורות 22-25). עתה מבקשים התובעים לחייב את הנתבע להשתתף בעלות מימון העבודות ודרישה זו יש בה משום חוסר תום לב. ויודגש, אין המדובר כאן במקרה של "זה נהנה וזה לא חסר" כפי שטוענים התובעים. התובעים בפעולותיהם החד צדדיות גרמו לנזקים למערכת הביוב ולדירת הנתבע. פסק דין כבר ניתן ואסר על התובעים לחבר מערכת ביוב חיצונית בשתי ערכאות. אף על פי כן, במשך למעלה מ- 3 שנים, טרם הוסדרו על ידם הליקויים שגרמו בצנרת הביוב הקיימת.

לאור האמור לעיל אני דוחה את התביעה למתן פסק דין הצהרתי לפיו רשאים התובעים להתקין צנרת ניקוז חיצונית.

אולם, לאור העובדה המוכחת (המוסכמת, למעשה, בין כל המומחים שהעידו בפני) כי לצורך חיבור דירת התובעים לצנרת הביוב הקיימת נדרש לבצע עבודות בתוך דירת הנתבע, אני מחייב את הנתבע לאפשר לתובעים גישה וכניסה לדירתו לשם ביצוע עבודות נדרשות לחיבור מערכת הביוב לרבות, ככל שיידרש, ביצוע חיזוקים ארעיים וקבועים בעמודי תמך ובתקרות. בעלות העבודות, לרבות, החזרת מצב דירת הנתבע לקדמותו, יישאו התובעים.

#### *הוצאות תחזוקת הבית*

התביעה בהקשר האמור הינה למתן סעד הצהרתי כללי. אין בתובענה פירוט של אותן עבודות שנדרש, לכאורה, לבצע ברכוש המשותף וכל שנתבע הוא סעד הצהרתי המורה לנתבע להשתתף בהוצאות להחזקתו התקינה של הבית.

מהראיות שהוצגו בפני עולה כי אין כל תחזוקה של הרכוש המשותף בבית. גם אין נציגות המנהלת את הרכוש המשותף. כך מעידה הגב' מכלוף – "הפסקתי להיות וועד בית כשהגשנו את התביעה הראשון פה בטאבו. הפסיק להיות וועד בית ב-ספטמבר כשהייתה התביעה הראשונה. אני מראה לעוה"ד חתימת הדיירים. השכנים נתנו לי. התפטרתי כשהיה המשפט הראשון ומאז אין וועד בית" (עמוד 11 שורות 27-29). כך גם עולה מהתביעה שכנגד, במסגרתה טוען הנתבע כי נשא בעצמו בעלויות לניקוי הרכוש המשותף בבית.

בנסיבות אלו, משלא הוכח בפני כי הנתבע סרב להשתתף בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף בבית, אין בידי לקבל את התביעה בהקשר זה. אף על פי כן, אפנה את הצדדים להוראות הדין והתקנון המחייבים את כל בעלי הדירות להשתתף על פי חלקם בהוצאות הנדרשות להחזקתו התקינה של הבית, קרי, שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 218/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

נוסף לכך, המדובר, למעשה, בעתירה למתן סעד הצהרתי כללי שאין מקום לתיתו כאשר בידו התובע האפשרות לתבוע את הסעד המהותי (י. זוסמן טדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית, 1955) בעמ' 562). ויודגש, התובעים אומנם צירפו במסגרת ראיותיהם את חוות דעתו של מר מרדכי בס. דא עקא, הם לא עתרו לסעד בהתאם לחוות הדעת האמורה למעט בכל הקשור לתיקון בעיות איטום במקלט ובקירות החיצוניים. אולם, גם בהקשרים אלו לא עלה בידם של התובעים להוכיח כי נדרשים תיקונים להחזקת התקניה של הבית בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין").

כך מעיד מר בס כי "הייתי רק בדירה של טווינה לא ראיתי חדירה של מים מהקירות" (עמוד 6 שורה 6). כך גם מודה מר בס בחקירתו הנגדית כי המסקנות המצוטטות על ידו בחוות דעתו בנוגע למניעת חדירת רטיבות (סעיף 4.2 לחוות הדעת) אינן בנוגע לקירות חיצוניים אלא לאטימה מצנרת (עמוד 6 שורות 12-7). כל שנותר אם כן הוא התיאור החיצוני של קירות הבית (סעיף 4.1 לחוות הדעת) ללא כל ממצא עובדתי לקיומה של רטיבות כלשהי החודרת לפנים הדירות בבית. בנסיבות אלו לא ברור כלל כיצד הגיע מר בס למסקנות המפורטות בסעיף 4.3 לחוות דעתו, בדבר העבודות המאסיביות הנדרשות בבית (בהיקף של כ- 100,000 ₪) וממילא לא הוכח כי העבודות המוצעות נדרשות לשם מניעת חדירת רטיבות מהקירות (שאיננה קיימת כלל).

כך גם לא הוכח כי כיום יש עוד בעיה של נזילה למקלט הבית. מר בס אינו מציין בחוות דעתו כי המקלט מוצף מים או כי קיימת בו בעיה של נזילת מים כלשהי. הדבר גם לא עולה מהתמונות שצורפו על ידו לחוות דעתו (צילומים 5 ו-6). גם בעדותו הוא מאשר "כשביקרתי במקום לא ראיתי מי גשם במקלט" (עמוד 6 שורה 19).

כך גם מעיד התובע כי "השנה יכול להיות שהמקלט יבש" (עמוד 8 שורה 10) וזאת בניגוד לאמור בתצהירו לפיו "המקלט של הבית המשותף מוצף דרך קבע במים והופך לבריכת שחיה" (סעיף 63 לתצהיר). מעדותו של התובע עולה כי כל תביעת התובעים בהקשר זה מתבססת על כך שבשנה שעברה היה המקלט מוצף (עמוד 8 שורות 12-11). אף אם נכון הדבר שבעבר היה המקלט מוצף, עדין אין בכך ללמד על קיומה של בעיה מבנית או ליקוי המחייב עבודות להחזקת הרכוש המשותף. בהחלט יתכן כי היתה בעבר נזילה למרתף שתוקנה, תתכן גם הצפה במקלט עקב עבודות בניה כאלו ואחרות שבוצעו בבית, והרי אין מחלוקת כי במהלך 3 השנים האחרונות לפחות נמצאים הצדדים בהליכים משפטיים ומערכת הביוב בבית טרם הוסדרה. מכל מקום, גם העבודות המוצעות בחוות הדעת של מר בס בהקשר זה אינן מלמדות על ליקויים במרתף אלא אך המדובר בעבודות מוצעות לביצוע תוספות שונות בגרם המדרגות בירידה למקלט. אלו, אינן עבודות להחזקת הרכוש המשותף וממילא לא הוכח כי יש בהן צורך (ר' גם סעיף ג בעמוד 12 לחוות דעת קליין).

בחוות הדעת של מר בס מועלית גם הצעה לפתרון הנדסי לניקוז מי הגשמים מגגות הבית. דא עקא, סעד בהקשר זה לא נתבע. כמו כן, בעדותו של מר בס הוא מאשר כי בניגוד לאמור בחוות דעתו נדרש תיקון רק למרזב אחד החודר אל הקרקע ולא "למרזבים (גשמות) אשר עוברים בפנים עמודי הבטון וחודרים אל הקרקע וברובם סתומים" (עמוד 6 שורות 18-17 וסעיף 6.1 לחוות הדעת). זאת



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 218/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

ועוד. מחוות דעתו של מר בס עולה כי הפתרון ההנדסי המוצע על ידו נועד "לפתור את הניקוז של של דירת המזמינים (התובעים דנן, א.ס.)" (סעיף 6.2 לחוות הדעת). משכך, ממילא לא הוכח כי המדובר בליקוי ברכוש המשותף המחייב תיקון במימון כל בעלי הדירות.

לכל זאת יש להוסיף כי על פי חוות דעתו של מר קליין, שלא נסתרה, ניתן לעשות שימוש במערכת המרזבים התקינה הקיימת לניקוז שטחי הגגות (עמוד 11 לחוות דעתו).

### פרגולה

התובעים עותרים להסרתה של "פרגולה" שהותקנה על ידי הנתבע בשטח הגינה המהווה רכוש משותף. את אותה "פרגולה" ניתן לראות בתמונה נספח ט"ז לתצהיר התובע ובמוצג ת/3.

הגב' מכלוף מאשרת בעדותה את התמונות הנ"ל. אולם, לטענתה, אין המדובר בפרגולה אלא בסוכה ניידת - "זה לא עץ זה סוכה שקונים אותה. זה לא כיסוי. החום הזה זה הסכך של הסוכה" (עמוד 12 שורה 15). בכתב ההגנה נטען עוד כי הסוכה מותקנת מידי חג סוכות.

עיון בתמונות שהוצגו מלמד על כי "הסוכה" נותרת בשטח הרכוש המשותף באופן קבוע. הדיון בפני התנהל, כאמור, בחודש 12/11, כ- 3 חודשים לאחר חג הסוכות, ואף על פי כן הקונסטרוקציה נותרה במקומה. למעשה, גם מעדותה של הגב' מכלוף עולה כי קונסטרוקציית הברזל מותקנת באופן קבוע (ר' סעיף 42 לתצהירה). זאת ועוד, מן התמונות ניכר כי, אומנם, קונסטרוקציית הברזל אופיינית לכזו המשמשת לבניית סוכות. אולם, הקירוי הינו קורות עץ ומעליהן בד בריזנט ירוק. קירוי זה אינו קירוי ארעי ובודאי שאינו קשור לחג הסוכות. מן התמונות ניכר גם כי בתוך שטח ה"סוכה" מאוחסן ציוד - שולחן אוכל וכסאות, אופניים וכיוצא ב.

בנסיבות אלו לא ניתן לומר כי המדובר בסוכה המותקנת לטובת חג סוכות אלא במבנה קבע שהותקן על ידי הנתבע בשטח הרכוש המשותף.

לאסיפה הכללית בבית ישנה סמכות להחליט על השימוש שיעשה ברכוש המשותף (ראה: ע"א 93/84 שלמה קדמי ואח' נ' קווין יערי ואח' פ"ד מ(1) 724). בהעדר החלטה מסוימת שכזו של האסיפה הכללית רשאי כל בעל דירה להשתמש ברכוש המשותף בהתקיים שני תנאים מצטברים:

התנאי הראשון, כי השימוש המבוצע הינו שימוש רגיל וסביר, קרי, שימוש אשר תואם את יעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות. תנאי המקום משמעם המקום בו הבית המשותף נמצא או ייעוד הבית המשותף (מגורים, מסחרי, משרדים וכד'). תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שהמציאות מתיבה (ראה: פרופ' י' ויסמן דיני קניין - בעלות ושיתוף (תשנ"ז) בעמ' 488-490).



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 218/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

התנאי השני, כי השימוש אותו מבצע בעל דירה ברכוש המשותף אינו מונע שימוש דומה מאחרים (ר' ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה פ"ד כ"ח (1) 645; ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג פ"ד כח (2) 817; ע"א 458/82 וילנר נ' גולני פ"ד מב (1) 49 וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה (4) 277).

במקרה דנן לא נטען וממילא לא הוכח על ידי הנתבע כי נתקבלה בידו הסכמה של בעלי הדירות בבית להתקנת "הסוכה".

כאמור לעיל, הוכח כי הסוכה עומדת בחצר הבית באופן קבוע ולא נעשה בה שימוש ארעי למשך חג הסוכות בלבד. הותרתה של ה"סוכה" באופן קבוע למשך כל ימות השנה לשימוש בלעדי של הנתבע אינו תואם את כוונת הצדדים או את תנאי הזמן והמקום בנוגע לשימוש בחצר משותפת. פעולת הנתבע בהתקנת הסוכה הקבועה כמוה כסיפוח בפועל שלא כדין של שטח החצר המהווה רכוש משותף לדירת הנתבע, בפרט לאור השימוש המבוצע בשטח הפרגולה והציוד המאוחסן שם כמפורט לעיל. ברי כי שימוש הנתבע בשטח החצר באופן האמור גם מונע שימוש זהה מאחרים.

ויודגש, לשאלה בדבר קיומו של היתר בניה או להכרח החוקי לקיומו של כזה להתקנת ה"סוכה" אין כל נפקות לצורך ההכרעה בתובענה דנן. דיני התכנון והבניה שונים בתכלית מדיני הקניין והסוגיות הנדרשות להכרעה בכל אחד מהן שונות. במקרה דנן התקנת ה"סוכה" על ידי הנתבע ברכוש המשותף, כמוה כהתקנת כך סוכך אחר בשטח הרכוש המשותף וככזו מחייבת היא קבלת הסכמה של בעלי הדירות בבית, בין אם נדרש לכך היתר בניה ובין אם לאו.

לאור האמור לעיל אני מקבל את התביעה בהקשר זה ומורה לנתבע לפרק את ה"סוכה" בחצר הבית לרבות קונסטרוקציית הברזל. אין באמור לעיל לגרוע מזכות הנתבע להתקין סוכה בשטח הרכוש המשותף במהלך חג הסוכות בלבד ולפרקה בסמוך לאחר גמר החג.

#### תביעה שכנגד

#### פתח הכניסה לגג

התובע שכנגד טוען כי הנתבעים אטמו פתח כניסה ישירה לגג המשותף שהיה קיים ברחבת הכניסה שליד דלת דירת הנתבעים שכנגד.

הנתבעים שכנגד טוענים כי מעולם לא היה פתח עליה לגג כפי שנטען וממילא הסוגיה הוכרעה כבר במסגרת ההליך הקודם וחל הכלל בדבר מעשה בי-דין.

עיון בפסק הדין בהליך הקודם מלמד כי בהקשר דנן הדין הוא עם הנתבעים שכנגד. כשם שקם מעשה בית דין בנוגע להכרעות בדבר צנרת הביוב החיצונית, כך גם קם מעשה בי-דין בנוגע לעילת התביעה בהקשר זה.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 218/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

מכתב התביעה בהליך הקודם עולה כי נתבעו, בין היתר, הסעדים "להורות לנתבעת להשאיר דוד השמש וקולטיו במקומם. לאפשר כניסה חופשית, מדרגות בחוץ כטאבו. לעירייה הגישה זיוף" (נספח ב' לתצהיר מכלוף). כלומר, במסגרת ההליך הקודם כבר פנה התובע שכנגד בבקשה למתן סעד שיורה להותיר פתח ומדרגות חיצוניות לגג. תביעה זו של התובע שכנגד נדחתה בהליך הקודם משנקבע כי גג הבית צמוד לנתבעים שכנגד דנן והוענקה להם הזכות לבנות על הגג בכפוף לקבלת היתר בניה כדין. ממילא גם לא נתקבלה הטענה כי לתובע שכנגד זכות גישה ישירה לגג או כי היתה כזו בעבר.

עילת התביעה לפיה יש להותיר פתח עליה לגג מן הרכוש המשותף כבר נדונה ונדחתה בהליך הקודם. כל שהשתנה בין ההליכים הוא הסעד המבוקש – בהליך הקודם, עובר לבניה, הסעד היה סעד הצהרתי. בהליך דנן, לאחר הבניה, הסעד המבוקש הוא צו עשה. **בשני ההליכים עילת התביעה זהה. לפיכך, ברי כי קם במקרה דנן מעשה ביי-דין מסוג השתק עילה.**

אולם, למען שלמות התמונה נעיר כי גם לא עלה בידי התובע שכנגד להוכיח כלל את טענתו בדבר קיומו של פתח גישה לגג בעבר.

תמונות הגג עובר לביצוע העבודות על ידי הנתבעים שכנגד (נספח יט לתצהיר הנתבע שכנגד) מלמדות על כי המדובר היה בגג מרוצף. מן התמונות ניכר כי לא היה בריצוף כל פתח מהקומה שמתחתיו. למעלה מכך, במיקום שנטען על ידי התובע שכנגד כי היה ממוקם הפתח (עמוד 12 שורה 7) היה מוצב מחסן בקומת הגג. ברי כי לא ניתן היה לעלות לגג דרך אותו המחסן. זאת ועוד. להבדיל מגגות הבתים הסמוכים (בהם ישנו פתח יציאה לגג), הרי שבבית דנן ישנה בניה במפלס הגג - חדר יציאה לגג, ריצוף וגדר. לעומת זאת, בבתים הסמוכים, המדובר בגג משותף ללא כל בניה או ריצוף (נספח יח לתצהיר הנתבע שכנגד).

למעשה, בידי התובע שכנגד גם אין כל ראיה לקיומו של פתח גישה כאמור בבית. הגב' מכלוף מעידה כי היא לא עלתה בפתח, לטענתה היא רק ראתה אותו (עמוד 12 שורה 8). היא גם טענה בתחילה כי בידה תמונה של הפתח אך בהמשך חקירתה הודתה כי "אין לי תמונה של הפתח. מה שיש לי זה תשריט" שהוגש כמוצג ת/1 (עמוד 12 שורה 11).

גם תשריט הבית המשותף (מוצג ת/1) מלמד על כי אין ממש בטענת התובע שכנגד. מן התשריט ניכר כי אין בגג כל פתח! הסימון לגביו מתייחסת הגב' מכלוף בעדותה הינו שרטוט של תקרת המבואה. לו היה פתח, במקום שבו נטען על ידה, הרי שהיה מופיע בתוך שרטוט תקרת המבואה סימון נוסף של פתח עליה לגג. דא עקא, בתשריט שטח הגג מופיע רציף ואחיד ללא סימון לקיומו של פתח כלשהו.

יוצא, אם כן, כי כל הסתמכות התובע שכנגד בהקשר זה היא על מצבם של הבתים השכנים (סעיף 46 לתצהיר מכלוף) ואין בידו כל ראיה לקיומו של פתח לגג הבית בעת כלשהי – לא תשריט, לא תמונה ולא כל עדות אובייקטיבית אחרת.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 218/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

מקובלת עלי גם עדותו של הנתבע שכנגד בהקשר זה "לא אטמנו את פתח הכניסה לגג. בכלל לא היה כניסה שם. ש.ת. נספח ג' לתצהיר. לא סגרנו את הפתח. לא היה פתח. וגם כשקנינו את הבית לא היה פתח. כשקנינו את הבית היו מדרגות לולייניות מתוך הדירה. אפשר לראות בתמונה הישנה מהזמן שאנחנו קנינו. הבית נראה מוזנח. לא היה שום חור לא היה כלום ולא עלייה לגג. נספח יז – זה הבית כשקנינו. ש.ת. כשקנינו את הבית לא היה שום דרך לעלות מבחוץ לגג. מחלוף אף פעם לא עלו לגג. נספח יט – תמונה שאפשר לראות מיותר קרוב. לא יכול להיות במבוא הזה מדרגות לעלות למעלה וגם לא היה שום פתח כשקנינו את הדירה" (עמוד 8 שורות 12-18). בפרט אמורים הדברים כשעדות זו נתמכת בראיות האחרות בתיק זה – תמונות הבית לפני הבניה ובעיקר תשריט הבית המשותף שנרשם כאמור לעיל.

לאור האמור לעיל אני דוחה את התביעה שכנגד לחיוב הנתבעים שכנגד לפתיחת פתח יציאה ישירה לגג.

*סגירת מרפסת וחלון*

גם בנוגע לעילת תביעה זו קם מעשה בי-דין מסוג השתק עילה.

במסגרת ההליך הקודם עתר התובע שכנגד לסעד "לא לתת שום היתר לשום בנייה, לשום הוספה או שינוי בין בקשיחה ובין ברכה" (נספח ב' לתצהיר מכלוף). מן הבחינה הקניינית תביעה זו נדחתה, למעשה, כבר בפסק דין חלקי מיום 21.09.08. בפסק הדין החלקי נקבע כי לנתבעים שכנגד דנן גג צמוד וזכות לבנות על אותו הגג בהתאם להוראות התקנון המוסכם ולפיכך נאסר עליהם לבצע בניה רק עד לקבלת היתר בניה כדין. על הכרעה זו חזרה כבוד המפקחת הבכירה אריאלי בפסק הדין הסופי בתובענה מיום 30.11.08.

משכך, עילת התביעה שעניינה בניה שביצעו הנתבעים שכנגד בבית כבר נדונה והוכרעה במסגרת ההליך הקודם. גם בהקשר זה, התביעה בהליך הקודם ביקשה סעד צופה פני עתיד (צו מניעה לפני ביצוע העבודות). בתובענה דנן מתבקש סעד צופה פני עבר (צו הריסה לאחר ביצוע העבודות). המדובר בסעדים המהווים את שני צידי המטבע של אותה עילה.

לכך יש להוסיף כי מאז ההליך הקודם ניהל התובע שכנגד הליך נוסף כנגד הנתבעים שכנגד בבית משפט השלום, בגין נזקים שנגרמו לדירתו עקב עבודות הבניה שביצעו הנתבעים שכנגד. צודקים הנתבעים שכנגד כי גם את הסעד הנתבע בנוגע לסגירת המרפסת, ככל שלדעת התובע שכנגד לא נכללה בהליך הקודם, היה עליו בודאי לכלול במסגרת ההליך בשלום כאחד מן הסעדים הנובעים מעילת התביעה – הבניה שביצעו הנתבעים שכנגד ונזקים כתוצאה הימנה. משלא עשה כן התובע שכנגד, הרי שבהתאם להוראות תקנה 44(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 אין הוא רשאי עוד להגיש תובענה בגין חלק זה.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 218/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

לבד מן האמור לעיל הרי שאף לא הוכח, לגופם של דברים, כי יש מקום ליתן לתובע שכנגד את הסעד המבוקש.

התובע שכנגד טוען כי סגירת המרפסת פוגעת בחזות הבית, מכערת אותו, מורידה את ערכו ונעשתה ללא קבלת היתר בניה כדין וללא קבלת הסכמה של בעלי הדירות בבית. דא עקא, לא עלה בידי התובע שכנגד להוכיח את עילת תביעתו בהקשר זה.

לא הוגשה על ידי התובע שכנגד כל חוות דעת מקצועית בנוגע להורדת ערכו של הבית או לעובדה כי הבניה בוצעה בניגוד להיתר בניה כדין. די בכך כדי להביא לדחיית טענותיו בהקשר זה.

מן התמונות שצורפו בהליך זה עולה כי לא רק שסגירת המרפסת איננה מכערת או מורידה את ערכו של הבית, אלא שפעולות הבינוי שביצעו הנתבעים שכנגד רק שיבחו את צורתו החיצונית. די בהשוואת התמונה המשקפת את מצב הבית כיום לתמונה המשקפת את מצב הבית עובר לביצוע העבודות על ידי הנתבעים שכנגד כדי לבסס את האמור (נספחים יט לתצהיר הנתבע שכנגד).

זאת ועוד. מן התמונות הנ"ל ניכר בבירור כי המרפסת שנטען כי נסגרה על ידי הנתבעים שכנגד היתה סגורה כבר במצב הקודם, עוד לפני ביצוע העבודות על ידם. לכך יש להוסיף כי גם מרפסת דירת התובע שכנגד, הממוקמת מתחת למרפסת דירת הנתבעים שכנגד, סגורה אף היא בחלוונות וסורגי ברזל לכל אורכה.

ההלכה אומנם מצמצמת את יכולת הפגיעה של בעל דירה ברכוש המשותף ללא קבלת הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. אולם, כבר נקבע כי חובת תום הלב חלה גם על מערכת היחסים שבין בעלי דירות בבית משותף (ע"א 810/82 זול בו בע"מ נ' זיידה ואח' פ"ד ל"ז (4) 737, בע"א 579/83 הרי זוננשטיין ואח' נ' אחים גבסו בע"מ קבלני בנין ואח' פ"ד מב(2) 278, רע"א 7112/93 צודלר ואח' נ' ש. יוסף ואח' פ"ד מח (5) 550 ורע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון פ"ד נ"ח(1) 199). בנוסף קובעות הוראות חוק המקרקעין כי "בעלות וזכויות אחרות במקרקעין, אין בהן כשלעצמן כדי להצדיק עשיית דבר הגורם נזק או אי נוחות לאחר" (סעיף 14 לחוק). ההלכה קבעה בהקשר זה כי "אין להתיר את השימוש בזכות הבעלות כעילה לגרם נזק או אי-נוחות אפילו למסיג-גבול, מקום שהשימוש בעילה זו אינו דרוש באורח סביר למימוש זכות הבעלות עצמה או למטרה חוקית אחרת" (בע"א 782/70 רדומילסקי נ' פרידמן פ"ד כה (2) 523 בעמ' 530).

אומנם, הנתבע שכנגד הודה כי לא קיבל את הסכמת בעלי הדירות בבית לביצוע העבודה (עמוד 7 שורה 17). אולם, העובדה כי לא הוכחה כל פגיעה בבית, כי הנושא כבר נדון בהליך קודם, כי הנושא כלל לא עלה בהליך בשלום, כי המרפסת נסגרה עוד לפני ביצוע העבודות על ידי הנתבעים שכנגד וכי אף התובע שכנגד עצמו סגר את אותה המרפסת בדירתו בחלוונות וזוכית וסורגים גבוהים, מצדיקה דחיית התביעה בהקשר זה. לכך יש להוסיף כי גם לא הובאו לעדות בפני בעלי דירות אחרים בבית אשר מתנגדים לסגירת המרפסת כפי שבוצעה. עמידת התובע שכנגד, לבדו, על



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 218/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

תביעתו בהקשר זה (בפרט כאשר המדובר בתביעה שכנגד שלא באה לעולם אלא כתגובה לתביעה העיקרית שהגישו התובעים), מהווה שימוש בזכותו הקניינית של התובע שכנגד בחוסר תום לב.

*תיקון קירות הבית*

התובע שכנגד עותר למתן צו אשר יחייב את הנתבעים שכנגד לצבוע בלבן את קירותיו החיצוניים של הבית. אין בידי לקבל תביעה זו.

ראשית, מניסוח כתב התביעה עולה כי המדובר בסעד הנובע, גם הוא, מנזק שנגרם לבית עקב בניה שבוצעה על ידי הנתבעים שכנגד. על התובע שכנגד היה לכלול גם את הסעד האמור במסגרת התביעה בהליך בשלום שעסק, כאמור, בנזקי הבניה. משלא עשה כן התובע שכנגד אין הוא יכול לתבוע עתה סעד זה (ר' דיון לעיל).

שנית, אין בידי התובע שכנגד ולו בדל של ראיה המצדיק חיוב בביצוע עבודות צביעה בלבן של קירותיו החיצוניים של הבית. אין בידי התובע שכנגד גם כל ראיה כי על הנתבעים שכנגד החבות לביצוע העבודות האמורות.

בהקשר זה יוזכר כי קירות הבית הינם רכוש משותף בהתאם להוראות סעיף 52 לחוק המקרקעין. לפיכך, על פניו, החבות הינה של בעלי הדירות כולם לביצוע עבודות, ככל שנדרש, לתחזוקה תקינה של הרכוש המשותף. גם בהקשר זה לא עלה בידי התובע שכנגד להמציא כל חוות דעת מקצועית לפיה ישנו קשר כלשהו בין מצב הקירות החיצוניים של הבית לבין העבודות שביצעו הנתבעים שכנגד. חוות דעתו של מר קליין איננה עוסקת כלל בשאלה זו. בהקשר דנן התייחסות מר קליין בחוות הדעת הינה אך לתקינותה או אי תקינותה של מערכת ניקוז מי הגשמים בבית. למעשה, העדות היחידה בהקשר זה הינה בחוות דעתו של מר בס מטעם הנתבעים שכנגד וממנה עולה כי המצב של הקירות החיצוניים של הבית נובע מגילו של המבנה ולא עקב עבודות שביצעו הנתבעים שכנגד (סעיף 4.1 לחוות הדעת).

*פינוי פסולת בניה*

הנתבעים שכנגד טוענים כי פסולת הבניה הותרה על ידם במקום רק במהלך הבניה, רק בכניסה לדירתם וממילא הכל כבר פונה ונקי - "ראיתי את התמונות שצירפתם על פסולת. זה בחצר של הכניסה של הבית שלנו. יש כניסה אלינו ויש כניסה אליהם. יש שתי כניסות נפרדות. שני שערים. השארנו פסולת במהלך השיפוץ רק בחלק שלנו. זה לא מהיום זה כבר 8 חודשים שהכול נקי. אני לא יודע בדיוק מתי צולמו התמונות" (עמוד 7 שורות 28-30). בסיכומיהם מפנים הנתבעים שכנגד לתמונה בנספח ג' לתצהיר מר טווינה כעדות לכך שפסולת הבניה אכן סולקה (סעיף 57 לסיכומים). דא עקא, בנספח ג' הנ"ל ניכר כי עדיין ישנם שקים של חומרי בניה ופסולת בניה שונה. אומנם אלו מונחים בצד החזית שליד המדרגות העולות לדירת הנתבעים שכנגד. אולם, עדיין, המדובר בפסולת בניה המונחת על גבי שטח המהווה רכוש משותף.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 218/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

לאור האמור לעיל אני מקבל את התביעה שכנגד בהקשר זה ומורה לנתבעים שכנגד לסלק את פסולת הבניה שהונחה על ידם בכל תחומי הרכוש המשותף.

**החזר הוצאות להחזקת הרכוש המשותף**

כאמור לעיל, אין מחלוקת כי התובע שכנגד אינו נציגות הבית המשותף. למעשה, אין נציגות כזו. לפיכך, המדובר בתובענה אישית של בעל דירה כנגד בעלי דירה אחרים לתשלום השתתפות בהוצאות שהוציא, לטענתו, להחזקת הרכוש המשותף.

בנסיבות אלה, על התובע להוכיח התקיימותם של ארבעה תנאים מצטברים: כי היה פגם ברכוש המשותף, כי ההוצאות היו סבירות בנסיבות הענין, כי התיקון היה מחויב המציאות וכי התיקון בוצע ברמה סבירה (עא (י-ם) 4371/03 יעקב עבר הדני נ' יהודה ושמחה גרייב חודידה (פורסם בנבו) וע"א (מחוזי-י-ם) 179/84 רוס נ' נציגות הבית המשותף פ"מ תשמ"ה(3), 418).

לאחר שקילת הראיות בתיק זה הרי שלא עלה בידי התובע שכנגד להוכיח את תביעתו בהקשר האמור.

כל הוכחת התביעה בהקשר זה מתבססת על עדותה של הגב' מכלוף ללא כל חוות דעת מקצועית להוכחת רכיבי עילת התביעה כאמור לעיל.

זאת ועוד. אפילו את אותם בעלי מקצוע אשר ביצעו, כביכול, את העבודות הנטענות לא הביא התובע שכנגד למתן עדות בפני, ללא כל הסבר. במיוחד אמורים הדברים לגבי מר סמי מרעי (החתום על האישור מיום 10.07.11) אשר ביצע, לכאורה, עבודה בבית במהלך ניהול ההליכים דנן וקיבל בגינה תשלום בסך של 3,500 ₪. בנוגע למבצעים האחרים הרי שלמעשה אפילו שמם המלא אינו ידוע (עמוד 1 שורה 12). גם מן האישורים שצורפו (נספח יא לתצהיר מכלוף) לא ניתן לדעת מיהם אותם אנשים באשר אפילו שם לא מופיע באותם המסמכים (כך בודאי לגבי שלושת האישורים הראשונים).

ההלכה קובעת בהקשר זה כי "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"י לה (1) 760, 736 ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רוזנברג ואח' פ"ד מז (2) 606 וכן ע"א 9656/05 שוורץ נ' רמנוף (פורסם בנבו) וע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' מתתיהו פ"ד מה(4) 651). מש



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 218/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

לבד מכל האמור הרי שגם לא ניתן בנסיבות דנן ליתן כל ערך ראייתי לאותם אישורים שצורפו. החתימה המופיעה בשני האישורים הראשונים זהה לחלוטין בעוד כתב היד של האישור עצמו שונה, וזאת כאשר המדובר לכאורה באנשים שונים שביצעו את העבודות בתקופות שונות (בהפרש של כשנה בין עבודה למשניה). ברור גם כי מי אשר כתב את האישור השלישי (בעברית ברורה) אינו האדם אשר חתם עליו (בעברית לקויה ובספרות בשפה הערבית). בנסיבות אלו כלל לא ברור אם החותמים על המסמכים ידעו על מה הם חותמים או אם קיבלו את הסכומים אשר נטען כי קיבלו. ויודגש, אין המדובר בסכומים זניחים אלא בתשלומים של למעלה מאלף שקלים בכל אחת מהפעמים. לא ניתן בנסיבות כאלו, בהעדר עדות מקצועית ושל מבצעי העבודה בפועל, להסתפק ב"אישורים" בכתב יד שצורפו לצורך חיוב בעלי הדירות בבית בהשבת סכומים משמעותיים שטוען בעל דירה כי הוא שילם.

לכל האמור יש גם להוסיף כי לא עלה בידי התובע שכנגד להוכיח כי ההוצאות שהוציא, ככל שהוציא, היו בגין ביצוע עבודות להחזקת הרכוש המשותף ולא בגין עבודות שהוציא להחזקת שטח החצר המוחזק על ידו. במיוחד אמורים הדברים לאור הקביעה לעיל והתמונות העדכניות לפיהן עדיין קיימת פסולת בניה, לכל הפחות הצד החצר שליד גרם המדרגות לדירת הנתבעים שכנגד.

זאת ועוד. אין בראיות התובע שכנגד ולא בסיכומיו כל הסבר כיצד הגיע סכום התביעה לסך של 14,000 ₪. אם וככל שהמדובר בהוצאות להחזקת הרכוש המשותף הרי שממילא מחויבים הנתבעים שכנגד בתשלום חלקם היחסי בלבד. דא עקא, אין כל פירוט, ראיה או הסבר לגובה החוב הנתבע.

ויודגש, אם המדובר בדרישה לחיוב החזר מלוא ההוצאות לאור נזקים שגרמו הנתבעים שכנגד בעבודותיהם, הרי כי גם סעד זה (הנובע מאותה עילה) צריך היה להיכלל במסגרת ההליך בשלום כאמור לעיל ודי גם בכך להביא לדחייתו.

## סיכום

### תביעה עיקרית

1. אני דוחה את התביעה למתן פסק דין הצהרתי לפיו רשאים התובעים להתקין צנרת ניקוז חיצונית. אולם, לצורך חיבור דירת התובעים לצנרת הביוב הקיימת, אני מחייב את הנתבע לאפשר לתובעים גישה וכניסה לדירתו, לאחר תיאום מראש, לשם ביצוע עבודות נדרשות לחיבור מערכת הביוב הקיימת לרבות, ככל שיידרש, ביצוע חיזוקים ארעיים וקבועים בעמודי תמך ותקרות, לרבות, עיבוי עמודים, אף אם יהיה בכך כדי "לגזול" שטח מחדר השירותים בדירת הנתבע. בעלות העבודות, לרבות, עלויות החזרת מצב דירת הנתבע לקדמותו, יישאו התובעים.
2. אני דוחה את התביעה לחיוב הנתבעים לשאת בהוצאות תיקון בעיות איטום ורטיבות במקלט ובקירות הבית.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים

מס' התיק: 218/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב

3. אני מורה לנתבע לפרק בתוך 7 ימים את ה"סוכה" בחצר הבית לרבות קונסטרוקציית הברזל. אין באמור לעיל לגרוע מזכות הנתבע להתקין סוכה בשטח הרכוש המשותף במהלך חג הסוכות בלבד ולפרקה בסמוך לאחר החג.

תביעה שכנגד

1. אני דוחה את התביעה שכנגד לחיוב הנתבעים שכנגד בפתיחת פתח יציאה ישירה לגג.
2. אני דוחה את התביעה שכנגד לחיוב הנתבעים שכנגד להסיר את החלון ולפתוח את המרפסת בחזית הבית.
3. אני דוחה את התביעה לחיוב הנתבעים שכנגד בצביעה בלבן של קירותיו החיצוניים של הבית.
4. אני מחייב את הנתבעים שכנגד לפנות בתוך 7 ימים כל פסולת בניה שהונחה על ידם בשטחי הרכוש המשותף של הבית.
5. אני דוחה את התביעה לחיוב הנתבעים בתשלום הוצאות התובע שכנגד לניקיון הרכוש המשותף.

הוצאות ההליך

לאור התוצאות אליהן הגעתי בתביעה ובתביעה שכנגד אינני עושה צו להוצאות וכל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ז שבט תשע"ב, 20 פברואר 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן  
מפקח על רישום מקרקעין  
תל אביב